> causas que versem sobre crimes não violentos, por mais graves e repugnantes que sejam, se justifiquem repetidos decretos de prisão, salvo, evidentemente, circunstâncias extraordinárias, pois reiteradamente esta Corte tem assentado o caráter excepcional da prisão antecipada.
>
> Atípico, também, pelo fato de os decretos de prisão, submetidos a reexame das instâncias superiores, terem sido, em sua maioria, não confirmados, autorizando, assim, o juízo crítico lançado pelos impetrantes.
>
> Já tive a oportunidade de me manifestar acerca de situações em que se vislumbra resistência ou inconformismo do magistrado, quando contrariado por uma decisão de instância superior. Em atuação de inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito, o juiz irroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência funcional. É inaceitável, sob qualquer perspectiva, esse tipo de comportamento, felizmente, raro e pontual.
>
> Penso que não pode ser diferente o papel desta Corte e de nós juízes, pois é inaceitável, sob qualquer *fundamento ou crença, tergiversar com o Estado de Direito, com a liberdade do cidadão e com os postulados do processo legal".*

Fato de ainda maior gravidade estava consubstanciado na perseguição que o magistrado imprimiu aos advogados de defesa do acusado. Em 2007, um dos investigados na operação havia tentado evadir-se da prisão fugindo para o Paraguai, onde também mantinha residência.

Diante da evasão, o Juiz Sergio Moro adotou tática bastante heterodoxa de descoberta de seu paradeiro: oficiou todas as companhias aéreas para que prestassem informações sobre voos com origem em *Ciudad del Este*, no Paraguai, ou Foz do Iguaçu, com destino a Curitiba, a fim de que se encontrasse o investigado. Também mandou fazer o mesmo com os voos de Porto Alegre para Curitiba, já que os advogados do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

investigado, Andrei Zenkner Schmidt e Cezar Roberto Bittencourt, poderiam estar neles.

Sobre esse ponto, ainda mais contundentes foram as assertivas feitas pelo ilustre Ministro Celso de Mello, em voto divergente que reconheceu a suspeição do magistrado e determinou a anulação de todos os atos jurisdicionais por ele praticados.

Peço mais uma vez vênias para transcrever as palavras do Ministro Celso de Mello acerca da conduta do magistrado em questão: "*o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transformando-se a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador.*"

A despeito da decisão final denegatória da ordem, são valiosas as razões de decidir do julgado naquilo que aponta o caráter inaceitável e execrável da atuação do magistrado por transvestir-se do papel acusatório:

> "Processo Penal. *Habeas Corpus*. Suspeição de Magistrado. Conhecimento. A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de *habeas corpus* quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste *habeas corpus*, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o *writ*.
>
> 2. Atos abusivos e reiteração de prisões. **São inaceitáveis os comportamentos em que se vislumbra resistência ou inconformismo do magistrado, quando contrariado por decisão de instância superior. Atua com inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito o juiz que se irroga de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência funcional. Revelam-se abusivas as reiterações de prisões desconstituídas por instâncias superiores e as medidas excessivas tomadas para sua efetivação, principalmente o monitoramento dos**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> **patronos da defesa, sendo passíveis inclusive de sanção administrativa**.
>
> 3. Atos abusivos e suspeição. O conjunto de atos abusivos, no entanto, ainda que desfavorável ao paciente e devidamente desconstituído pelas instâncias superiores, não implica, necessariamente, parcialidade do magistrado. No caso, as decisões judiciais foram passíveis de controle e efetivamente revogadas, nas balizas do sistema. Apesar de censuráveis, elas não revelam interesse do juiz ou sua inimizade com a parte, não sendo hábeis para afastar o magistrado do processo. Determinada a remessa de cópia do acórdão à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e ao Conselho Nacional de Justiça. Ordem conhecida e denegada". (HC 95.518, Relator EROS GRAU, em que fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, julgado em 28.5.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 18.3.2014 PUBLIC 19.3.2014).

Infelizmente, a experiência acumulada durante todos esses anos nos mostra que os órgãos de controle da atuação da magistratura nacional falharam em conter os primeiros arroubos de abusos do magistrado. Após o julgamento desta Segunda Turma, em 2013, que ordenou a instauração de procedimento disciplinar à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e ao Conselho Nacional de Justiça, não houve nenhuma punição ao ex-juiz.

Além das estratégias adotadas pelo magistrado na mencionada operação Banestado, em outras oportunidades, sua conduta se direcionou à violação do preceito constitucional de sigilo da relação entre cliente e advogado – proteção constitucional que visa, ao fim e ao cabo, a garantir alguma possibilidade de ampla defesa no processo penal.

Ainda em 2009, a Ordem dos Advogados do Brasil oficiou ao ex-juiz Sergio Moro, relatando ter tomado conhecimento de que o magistrado mandara instalar escutas no parlatório do presídio federal de segurança máxima de Catanduvas, no Estado do Paraná. Sob a justificativa de que presos de alta periculosidade estavam segregados no estabelecimento, o ex-juiz monitorava as conversas entre os presidiários e seus advogados.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

O comunicado assinado pela OAB em protesto às atitudes do magistrado ressaltava que "*a existência e funcionamento desses aparelhos [de escuta] ultraja os direitos dos advogados de avistar-se, pessoal e reservadamente, com seus clientes, violando, ainda, a própria cidadania, o Estado Democrático de Direito e o sagrado direito de defesa*".

Como ressaltado em reportagem veiculada no Portal Conjur:

> "O Conselho Nacional de Justiça sequer analisou o pedido. A argumentação descrita acima consta de uma Reclamação Disciplinar levada à então corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. Mas, em 2011, ela arquivou a Reclamação com base na decisão do plenário do CNJ de arquivar um Pedido de Providências sobre o mesmo fato. A decisão era de que as gravações de conversas entre presos e advogados foram feitas no âmbito de processos judiciais. O caso, portanto, esbarrou na 'incompetência do CNJ para rever questões já judicializadas'". (disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-mai-05/excessos-sergio-moro-sao-discutidos-cnj-2005

Além desse procedimento, houve pelo menos outros 2 (dois) pedidos de providências contra o ex-juiz Sergio Moro que foram arquivados no CNJ. Em todos eles, discutia-se a atuação do magistrado para além dos limites de imparcialidade, como a prorrogação indefinida de interceptações telefônicas de investigados.

O início da Operação Lava Jato precipitou que o Supremo Tribunal Federal iniciasse a rever de forma mais corriqueira as decisões judiciais assinadas pelo excepto.

Ainda que a narrativa dos anos iniciais da Lava Jato no STF seja suscetível de manipulação por parte daqueles que pretendem se escusar de reconhecer as suas falhas, é com absoluta tranquilidade que posso rememorar as minhas posições críticas aos abusos cometidos pela República de Curitiba ainda nos primeiros processos que aportaram nesta Suprema Corte.

Em março de 2015, poucos meses após os processos da Lava Jato

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

chegarem ao Supremo, em julgamento pela Segunda Turma, manifestava preocupações com as decretações de prisões preventivas pela 13ª Vara Federal de Curitiba baseadas em fundamentação genérica.

Em julgamento em que se discutia a possibilidade de extensão de *habeas corpus* concedido ao ex-diretor da Petrobras Renato Duque, por ausência de fundamentação na decretação da preventiva, verbalizei a inquietação com a matéria ao afirmar, já à época, que: *a mim me [parecia] que* ***estávamos nos aproximando do limite em que a prisão preventiva se torna antecipação de execução, a não ser que haja outras justificativas***. (HC 125.555-Extn-terceira-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 21.5.2015).

A preocupação com a ampliação do uso de prisões cautelares também foi por mim ressaltada no julgamento do AgR na Rcl. 25.362, quando observei que "*[tínhamos] um encontro marcado com essas alongadas prisões que se determinam em Curitiba e [tínhamos] de nos posicionar sobre esse tema que, em grande estilo, discorda e conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos*". (Rcl 25.362 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.2.2017, DJe 2.8.2017).

Ainda em setembro de 2015, o Tribunal enfrentou o debate acerca da extensão da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar ações relacionadas à Operação Lava Jato. Na ocasião, esta Corte decidiu que a competência de Curitiba não tem contornos de universalidade sobre toda e qualquer investigação que envolva utilização de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas, mas, na verdade, restringe-se aos fatos especificamente relacionados a fraudes no Sistema Petrobras.

O Tribunal deixou claro que "*o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de fases da operação Lava-jato uma sequência de investigações sobre crimes diversos não se sobrepõe às normas disciplinadoras da competência*" e que "*nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários*" (Inq. 4.130 QO, Relator Min. Dias

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 23.9.2015, DJe 3.2.2016).

Este parece ter sido um primeiro e raro momento de lucidez desta Corte quanto às intenções espúrias da força-tarefa no sentido de se hastear sobre toda e qualquer investigação relacionada à criminalidade econômica no país.

Ainda no ano de 2016, continuei a insistir em chamar atenção para **os excessos na manutenção das prisões provisórias decretadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba**. No julgamento do HC 132.267/PR, impetrado por Marcelo Odebrecht, o próprio relator reconhecera que a prisão não mais se justificava para assegurar a aplicação da lei penal ou para garantia da ordem pública, mas a segregação cautelar foi mantida pela Segunda Turma como medida extrema pela conveniência da instrução criminal. Na ocasião, destaquei que: "*mesmo em casos rumorosos, **venho ressaltando a jurisprudência do Tribunal a propósito da excepcionalidade da prisão provisória**"*. Naquele caso, não se tinha qualquer notícia de colheita de provas em andamento que pudesse ser prejudicada pela libertação do paciente.

Nessa quadra, já me era claro que o expediente expansivo da Operação Lava Jato se desdobrava, inclusive, para o campo político. Em debate realizado no Senado Federal, em 4 de dezembro de 2016, manifestei-me sobre os desacertos das indigitadas 10 Medidas Contra a Corrupção, que, dentre outras hipóteses, proibiam a concessão de liminar em *habeas corpus* sem prévia requisição de informações ao promotor ou procurador. Na oportunidade, assentei:

> "Tenho impressão de que estamos vivendo momento singular […] Depois, esses falsos heróis vão encher os cemitérios, a vida continua. O resumo da ópera é: você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o ó do borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia, calcem as sandálias da humildade".

Mesmo sujeito às contingências do convencimento do Colegiado nas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

ações julgadas pela Segunda Turma e pelo Plenário, busquei advertir sobre os descomedimentos de um inovador e criativo modelo de justiça criminal negocial que se alastrava pelo país com os acordos de colaboração premiada da Lei 12.850/2013. No emaranhado de acordos negociados pela força-tarefa de Curitiba, podemos afirmar que vimos de tudo.

Ao apreciar a Questão de Ordem na PET 7.074, em que esta Corte discutia os poderes do relator para homologação dos acordos de colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo J&F, meu voto trouxe sérias advertências sobre os abusos cometidos pelo *Parquet* na celebração de tais acordos. Na ocasião, afirmei que estava convicto de que tínhamos que "*evoluir em soluções jurisprudenciais e legislativas reforçando a presunção de inocência, sem impedir as investigações*" (Pet 7.074 QO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2017, DJe 3.5.2018).

Na oportunidade, colhi um inventário de acordos que estipulavam sanções premiais que ultrapassavam o rol previsto na Lei 12.850/2013 (art. 4º, *caput*, §§ 2º e 4º). Ressaltei que, de forma progressiva, novos expedientes foram introduzidos tanto em benefício do colaborador quanto da acusação, conforme as tratativas das partes.

Alguns exemplos paradigmáticos merecem ser rememorados. Dois dos primeiros acordos de colaboração celebrados pela Operação Lava Jato, os de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, previam as seguintes condições, acordadas sem respaldo na legislação: (i) redução da pena de multa; (ii) início do cumprimento da pena privativa de liberdade com a celebração do acordo, independentemente de condenação; (iv) fixação de requisitos menos gravosos para a progressão de regime da pena privativa de liberdade; (v) suspensão de investigações e de procedimentos, após atingido o teto de pena privativa de liberdade em outras sentenças.

Diante de todas essas constatações, no julgamento da referida PET 7.074-QO, em meu voto, mesmo sem deixar de reconhecer os avanços que a Operação trouxera para o combate à corrupção no país, externalizei com veemência as minhas recalcitrâncias quanto às verdadeiras finalidades

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

dos membros da força-tarefa. Nesse sentido, destaquei à época que:

> "A preocupação [da Operação Lava Jato] em produzir volume de investigações, com ou sem futuro, parece ter-se tornado, com as vênias de estilo, ou sem vênias, um dos objetivos do Grupo de Trabalho da Procuradoria-Geral da República.
>
> (...) Os objetivos da Lava Jato não são imediatamente políticos. A disputa é por poder entre Poderes do Estado, inclusive subjugando o Judiciário, e não se está percebendo isso! Está-se submetendo o Judiciário agora ao crivo da Procuradoria, inclusive essas ações que são enjambradas para amedrontar magistrados.
>
> (…) Para além de vaidades pessoais, está em formação um quadro que permite que o Processo Penal domine o jogo político. Complementados pelo tapetão eleitoral costurado pela lei da ficha limpa, as investigações de macrocriminalidade das classes políticas e empresarial dão ao Ministério Público o poder de definir os rumos políticos do País; basta abrir um inquérito sem controle".

As censuras feitas por mim parecem ter se exacerbado diante do escancaramento dos desvios cometidos. Já alertava aqui, com alguma frequência, sobre o comportamento ardiloso com que os procuradores conduziam as investigações, em clara afronta aos limites da legalidade.

Na apreciação do HC 143.333/SP, impetrado por Antônio Palocci, dediquei parte do meu voto a denunciar que a corrupção já havia chegado à Procuradoria. Destacando os detalhes dos episódios de Marcelo Miller, afirmei:

> "Não queria falar sobre isso mais uma vez, Doutora Raquel, mas a corrupção já entrou na Lava Jato pela Procuradoria, ou alguém tem dúvida do episódio hoje está nos jornais da atuação de Fernanda Tórtima e Marcelo Miller? É um clássico de corrupção. Isso tem que ser investigado e tem que

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

ser dito. Veja, na medida em que vamos fechando o sistema e empoderando esses nichos, nós estamos dando azo. E eu estou dizendo que sou mau profeta. Eu falei aqui daquele acordo, na semana seguinte eclodiu aquela fita, agora os jornais de hoje noticiam que a JBS entrou nos Estados Unidos contra Trench Rossi Watanabe, pedindo indenização. É um caso seríssimo. As consequências políticas da opção que estamos fazendo são extremamente graves, porque nós perdemos o controle do sistema, o que decidirem será.

Ainda ontem eu relatava na Turma, Presidente estou mandando a Vossa Excelência amanhã , o episódio do auxílio-moradia dos juízes no Rio, em que um dos requerentes é o Doutor Bretas. E o que aconteceu nesse processo? Não estamos falando só de desvios, Presidente, que vão se acumulando, dessa gente empoderada que está aí. Um processo movido pelo Paulo Espírito Santo, Bretas e outros juízes, no Rio de Janeiro, perante um colega seu, para ganhar benefício de auxílio-moradia, embora vedado pelo CNJ, houve a liminar concedida e, depois, o mérito. A AGU não recorreu, também não houve recurso de ofício, e deram o processo como trânsito em julgado. Vejam o empoderamento que está acontecendo, Presidente, isso o pouco que a gente sabe, na conversa com os advogados, que certamente têm todos os seus cuidados em relação a isso.

(...) Não preciso adivinhar, isto já está prenhe de corrupção, no verdadeiro sentido da palavra. Quando vi esses dias que o Doutor Marcelo Miller recebeu um montante de indenização por conta daquele grampo do escritório, pensei: A Procuradoria é tão ágil para pedir indisponibilidade de bens de todo mundo, por que ainda não fez em relação ao Doutor Marcelo Miller? A sua prisão preventiva foi indeferida pelo Ministro Fachin, não houve recurso, mas é um caso sério, é um caso sério de corrupção! Não tem outra palavra! E isto está sendo alimentado por esse empoderamento, porque não se faz revisão. Isto é muito sério, Presidente". (HC 143.333, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12.4.2018, DJe 26.3.2019).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Em 16 de março de 2019, ainda antes de serem reveladas as mensagens do *The Intercept*, o Tribunal julgou o Inq. 4.435-Quarto-AgR – no qual se discutia a extensão da competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais, prevista no inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal e no inciso II do artigo 35 do Código Eleitoral –, oportunidade em que, mais uma vez, não me furtei de denunciar os abusos evidenciados (Inq. 4.435 AgR-quarto, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, DJe 21.8.2019).

Na ocasião, busquei deixar claro que a tentativa do Ministério Público de mudar a competência da Justiça Eleitoral, a qual permanecia incólume em todas as Constituições brasileiras, representava verdadeiro projeto de poder. Ressaltei:

> "É preciso o combate à corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crimes, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Assim se instalam as milícias brasileiras. Esquadrão da morte é fruto disto. É preciso ter cuidado. Quem investiga tem que observar o Estado de Direito" (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, DJe 21.8.2019).

Mesmo que seja fácil adotar a postura de profeta do acontecido, a minha biografia de Juiz Constitucional felizmente revela, de longa data, o enfrentamento dos abusos derivados do modelo de juiz acusador travestido pelo excepto.

Voltando ao exame da atuação do Supremo Tribunal Federal, sobrelevam-se decisões recentes desta Segunda Turma em que se reconheceu **com extrema perplexidade** que o ex-Magistrado Sergio Moro, reiteradas vezes, interferiu na produção de provas contra os acusados, direcionou o curso das investigações a partir da manipulação e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

tergiversação de depoimentos de colaboradores premiados, procedeu a juntada de ofício – sem provocação do Ministério Público – de provas documentais e testemunhais utilizadas para a fundação das próprias sentenças.

Em **4 de agosto de 2020**, no julgamento do Agravo Regimental no *Habeas Corpus* 163.943, esta Segunda Turma entendeu que Sergio Moro abusou do seu poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018. A rica fundamentação deste precedente será oportunamente discutida neste voto. Transcreve-se, no que importa neste momento, a ementa do acórdão:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA 691 DO STF. DECISÃO EX OFFICIO DE JUIZ QUE ORDENA, APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ÀS VÉSPERAS DO PRIMEIRO TURNO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2018, O LEVANTAMENTO DO SIGILO E O TRANSLADO AOS AUTOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE ANTÔNIO PALOCCI FILHO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE FLAGRANTE. ALEGADA APLICAÇÃO DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA ÀS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUEBRA, ADEMAIS, DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. DESENTRANHAMENTO DETERMINADO COM BASE NO ART. 157 DO CPP. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO SUCESSIVA DE MEMORIAIS ESCRITOS POR RÉUS COLABORADORES E DELATADOS. PERDA DE OBJETO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ PRONUNCIAMENTO FINAL DO COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA ONU. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUTELAR DO REFERIDO ORGANISMO INTERNACIONAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> CONCEDIDA. I – Conhecimento de habeas corpus, com superação da Súmula 691 do STF, nos casos em que, configurada a flagrante ilegalidade de provimento jurisdicional, resta evidenciado risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente (Precedentes, dentre outros: HC 87.926/SP, Relator Min. Cezar Peluso, e HC 157.627/PR, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski). II - Age com abuso de poder o juiz que ordena, de ofício, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial de 2018 e após encerrada a instrução processual, o levantamento do sigilo e o translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada. III – Decisão que, buscando influenciar, de forma direta e relevante, o resultado da disputa eleitoral, desvela comportamento, no mínimo, heterodoxo do julgador, em franca violação ao sistema acusatório e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV - Demonstrado o evidente constrangimento ilegal imposto ao recorrente, impõe-se o desentranhamento dos autos da delação levada a efeito por Antônio Palocci Filho, com esteio no art. 157 do CPP. V – Perda do objeto com relação ao pedido de adiamento da apresentação de alegações finais, após o decurso do prazo fixado para os corréus colaboradores. VI – Inviável o pleito de suspensão do julgamento da ação penal até o pronunciamento final do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porquanto tal medida não foi contemplada na cautelar expedida pelo organismo internacional. VII – Agravo regimental conhecido em parte, concedendo-se parcialmente a ordem no habeas corpus". (HC 163.943 AgR, Relator EDSON FACHIN, Relator do acórdão RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 9.9.2020 PUBLIC 10.9.2020)

Já em 25 de agosto de 2020, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso em *Habeas Corpus* 144.615/PR, a Segunda Turma do STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug ainda no

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

âmbito da chamada Operação Banestado, o Juiz Sérgio Moro "***se investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório".***

No caso, demonstrou-se que o magistrado, ao tomar diretamente depoimentos de colaboradores no momento da assinatura de acordo de colaboração premiada, participou da própria produção da prova na fase investigativa, exercendo, ao menos materialmente, as atribuições próprias dos órgãos de persecução. Além disso, verificou-se que, após a apresentação de alegações finais, o juiz teria determinado *ex officio* a juntada aos autos de documentos posteriormente utilizados para fundamentar a condenação, suprindo assim a insuficiência probatória da acusação, prevista no art. 156 do CPP.

Na apreciação deste caso, o Ministro Ricardo Lewandowski destacou que "*os elementos informativos reunidos evidenciavam, de forma irrefutável, que o magistrado de piso não se limitou a supervisionar a colheita da prova, tampouco cingiu-se a verificar a regularidade e espontaneidade das colaborações. Antes, o julgador atuou concretamente para a produção da prova da acusação em sede de investigação preliminar. E, ao que tudo indica, com unidade de desígnios com o órgão acusatório*". Com esses fundamentos a Segunda Turma declarou a nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos pelo Juiz Sergio Moro, ainda durante a fase pré-processual. Destaca-se a ementa do julgado:

> "Penal e Processual Penal. Imparcialidade judicial e sistema acusatório. Postura ativa e abusiva do julgador no momento de interrogatório de réus colaboradores. Atuação em reforço da tese acusatória, e não limitada ao controle de homologação do acordo. **As circunstâncias particulares do presente caso demonstram que o juiz se investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório**. Imparcialidade judicial como base fundamental do processo. Sistema acusatório e separação das funções de investigar, acusar e julgar. Pressuposto para imparcialidade e contraditório efetivos. Precedente: ADI 4.414, Plenário, Rel.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> Min. Luiz Fux, j. 31.5.2012. Agravo regimental parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida por violação à imparcialidade do julgador". (RHC 144.615 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, em que fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26.10.2020 PUBLIC 27.10.2020)

O olhar em retrospecto não esconde que **o Juiz Sergio Moro, por diversas vezes, não se conteve em "pular o balcão".** Na ordenação dos atos acusadores, o magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da exposição midiática dos acusados.

A opção por provocar – e não esperar ser provocado – garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores e, em especial, do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral.

Não é à toa que organismos e Tribunais Internacionais vêm, nos últimos anos, questionando a parcialidade do ex-magistrado na condução dos processos da Operação Lava Jato diante dos mecanismos heterodoxos por ele utilizados.

Nesse sentido, vale citar a decisão do Comitê de Controle de Arquivos da Interpol de 6 de agosto de 2018, que analisou demanda apresentada por Rodrigo Tacla Duran (CCF/106/R.808.16-18/c.3858.18), afirmando que seu eventual julgamento no Brasil, que seria realizado pelo ex-Juiz Sergio Moro, não respeitaria as regras do devido processo legal.

A partir dos fatos descritos, a Comissão assentou que "*em razão da conduta do juiz responsável pelo caso no Brasil, dúvida suficiente se estabeleceu sobre eventual violação do art. 2 da Constituição da Interpol*" de modo que "*as provas apresentadas, e facilmente verificáveis em fontes públicas, para fundamentar a alegação de que o juiz se pronunciou publicamente contra ele durante entrevista e, ao negar petições para que ele prestasse depoimento como*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

testemunha em outros casos, emitiu opinião a respeito da veracidade de qualquer informação que ele pudesse apresentar ".

Com esses fundamentos, a Interpol retirou Tacla Duran da lista de procurados, reconhecendo a fragilização da imparcialidade do ex-Juiz Sergio Moro.

Esse breve histórico de manipulações e violações da lei pelo magistrado, sobre as quais há muito venho refletindo, fez com que eu recebesse, na data de ontem (8.3.2021), com extrema naturalidade, a brilhante e histórica decisão monocrática de lavra do Ministro Edson Fachin, que determinou a anulação de todas as condenações impostas ao paciente, a partir do reconhecimento de que o ex-Juiz Sergio Moro não tinha competência para julgar as ações penais.

Ressalto, a propósito, que, nos últimos anos, tenho sido absolutamente enfático em expor que a 13ª Vara Federal de Curitiba tem adotado reiteradamente a estratégia de expandir de forma artificial a sua competência para se tornar um juízo universal de combate aos crimes de colarinho branco.

Além dos casos citados na decisão de ontem de lavra do Min. Edson Fachin, dos quais, na maioria, figurei como redator do acórdão (Pet 6.863 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 11.10.2018; Pet 8.090 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2020, DJe 11.12.2020), trago à baila decisão recente, de **4 de setembro de 2019,** em que declarei a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para processar e julgar o ex-Ministro Guido Mantega por fatos supostamente cometidos na cidade de Brasília-DF, que, somente de forma artificial, teriam relação com os ilícitos investigados na Petrobras. Na ocasião, ressaltei que:

> "A admissão da manipulação de competência nesses moldes possui sérias consequências sobre a restrição das garantias fundamentais de caráter processual dos indivíduos, em especial quanto ao juiz natural (art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> A situação verificada nos autos corrobora a necessária advertência feita pelo Plenário deste Tribunal, no sentido de que n**enhum órgão jurisdicional pode, à revelia das regras processuais de competência, arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas para fins político-partidários"**.

Ainda sobre esse ponto, cabe destacar as considerações lançadas em trabalho de notável valor acadêmico da **JUÍZA FABIANA ALVES RODRIGUES**, na qual a pesquisadora conclui que "*o tema da competência para julgar os casos da Lava Jato de Curitiba encerra o que talvez seja o melhor exemplo de ação estratégica usada para se esquivar da incidência dos preceitos legais, em busca dos resultados atingidos pela operação*". A autora aponta a estratégia adotada pelo Juiz Sergio Moro de não deixar claro, desde o início, quais seriam as circunstâncias probatórias que justificariam a conexão dos feitos e a prevenção da Vara Federal de Curitiba:

> "(...) Os fatos que justificaram a fixação da competência em Curitiba, não foi abordado nas decisões judiciais analisadas na pesquisa apresentada neste livro. O enfrentamento desse tema tem relevância porque há previsão legal de que a força atrativa da primeira ação criminal se encerre com o seu julgamento (artigo 82 do Código de Processo Penal). Basta constatar que Sérgio Moro se exonerou do cargo de juiz, e ninguém afirma que isso impede a análise dos casos remanescentes pelo juiz que os assumiu. Ou seja, as provas de um processo que são úteis para outro caso podem ser transferidas/copiadas, sem a necessidade de violar a regra geral que prevê que a competência deve ser determinada pelo local de consumação dos crimes.
>
> **As sentenças das ações criminais de Curitiba não esclarecem por que os julgamentos dependeram do conteúdo das provas produzidas na ação** 13. Ou seja, não há indicação de que realmente existia a alegada conexão probatória. A ação originária tem como crime mais grave a lavagem de dinheiro, que na denúncia não indica nenhuma ligação direta com a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> Petrobras ou seus diretores, pois consiste em investimentos feitos numa empresa situada na cidade de Londrina, PR. **A denúncia menciona que a lavagem de dinheiro tem como crime antecedente o de corrupção, praticado pelo ex-deputado José Janene, apurado no Mensalão. No julgamento final afirma-se, inclusive, que se trata de 'recursos do Fundo Visanet administrados pelo Banco do Brasil e recursos da Câmara dos Deputados'; além de 'empréstimos fraudulentos do Banco Rural' (item 160 da sentença). Se as provas produzidas nesse caso não têm nenhuma relevância para as investigações que se seguiram, não havia justificativa para a manutenção de todos os processos da Petrobras em Curitiba**.
>
> Na construção do argumento de conexão probatória, o crime de organização criminosa exerceu o papel de curinga para azeitar a narrativa de que todos os crimes praticados em prejuízo da estatal devem ser tratados em bloco, algo bem semelhante à análise feita por Arantes (2018) sobre o Mensalão.
>
> Essa narrativa possivelmente contempla dois objetivos: evitar a redistribuição dos processos a atores do sistema de Justiça menos comprometidos com os resultados; justificar a definição de uma linha de investigação que pressupõe a necessidade de identificar e punir a liderança da organização criminosa". (RODRIGUES, Fabiana Alves. **Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça**. WMF Martins Fontes: São Paulo, 2020, p. 222-224).

Todas essas circunstâncias mostram que os atos jurisdicionais praticados pelo ex-juiz denotam em toda sua complexidade a implementação de uma atuação acusatória proativa, seja para restringir a possibilidade de defesa dos acusados, seja para passar por cima dos limites da demarcação do princípio constitucional do juiz natural.

Esses antecedentes históricos, porém, são apenas faíscas de uma atuação concertada muito mais grave que acabou por ser relevada entre o magistrado e os órgãos de acusação. Atuação concertada essa que não escondia seu objetivo maior: inviabilizar de forma definitiva a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

participação do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva na vida política nacional.

5. Dos fatos novos: desnecessidade de utilizar elementos probatórios potencialmente ilícitos

Antes de iniciar a análise dos fatos narrados pela defesa como indicativos da quebra de imparcialidade do juiz, julgo necessário esclarecer questão que me parece preliminar sobre a licitude da utilização, como meio de prova, dos diálogos havidos entre o ex-juiz e os membros da força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba, apreendidos no âmbito da chamada Operação Spoofing.

Convém ressaltar que, no último dia 9 de fevereiro, esta Segunda Turma confirmou decisão de lavra do Ministro Ricardo Lewandowski que franqueara ao paciente o acesso aos diálogos obtidos a partir do acesso a contas do aplicativo Telegram. Na oportunidade, no entanto, este colegiado não avançou sobre a possibilidade de utilização dos mencionados diálogos para fins de produção probatória em ações penais.

Na oportunidade, o eminente relator Ricardo Lewandowski destacou que "*não estamos discutindo a validade das provas obtidas na operação spoofing. Isso é matéria que será discutida eventualmente em outra ação, se e quando a defesa fizer uso delas. Aqui estamos discutindo o acesso aos elementos de prova que há três anos vem sendo denegado à defesa do reclamante*" (Rcl. 43.007, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9.2.2021, acórdão pendente de publicação).

Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz federal Sergio Moro. Assim, fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar três situações de evidente ilegalidade:

> 1. Julgador define os limites da acusação e seleciona pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes;
>
> 2. Julgador indica testemunha para a acusação e sugere meios ilícitos para inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar a sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima;
>
> 3. Julgador atua em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas.

Por óbvio, **não se quer aqui vedar qualquer contato entre julgador e as partes do processo**. Em prol do contraditório, é louvável a abertura de juízes para receber as partes e obter mais elementos para embasar a tomada da decisão a partir dos fatos provados no processo e das regras legais, constitucionais e convencionais. Inclusive, trata-se de dever do julgador, nos termos do Estatuto dos Advogados do Brasil e nos limites ali previstos.

Contudo, neste caso concreto, o contato entre o julgador e os atores acusatórios foi muito além do mero exercício do contraditório. Aqui, há **clara aderência do julgador às pretensões da acusação, refletida em ações de aconselhamento, por parte do juiz, para contribuir ao resultado condenatório pretendido ao processo de um modo preconcebido.**

Ainda que a veracidade das mensagens divulgadas pela mídia não tenha sido cabalmente demonstrada, os atores envolvidos reconheceram a ocorrência de conversas e reuniões entre julgador e acusadores, no sentido de colaboração recíproca.

Recentemente, ao comentar a conversa em que sugere testemunha a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

ser chamada pela acusação, Sergio Moro declarou que: "*Nós, lá na 13ª Vara Federal, pela notoriedade das investigações, nós recebíamos várias dessas por dia. Eu recebi aquela informação e, aí assim, vamos dizer, foi até um descuido meu, apenas passei pelo aplicativo. Mas não tem nenhuma anormalidade nisso. Não havia nem ação penal em curso*" (Folha, 14.6.2019).

Cumpre lembrar os fundamentos que utilizei para considerar os elementos de informação aportados no caso em que suspendi a nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como Ministro em 2016, por desvio de finalidade do ato. Naquela oportunidade, afirmei que:

> "No momento, não é necessário emitir juízo sobre a licitude da gravação em tela. Há confissão sobre a existência e conteúdo da conversa, suficiente para comprovar o fato. (...)
>
> Ou seja, há uma admissão pessoal da existência da conversa e da autenticidade do conteúdo da gravação.
>
> Estamos diante de um caso de confissão extrajudicial, com força para provar a conversa e seu conteúdo, de forma independente da interceptação telefônica. Aplica-se, aqui, o art. 212, I, do Código Civil combinado com o art. 353 do Código de Processo Civil, vigente por ocasião das declarações: (...)
>
> A confissão não mereceria invalidação pelo nexo com a prova ilícita – gravação sem autorização. A admissão foi espontânea, na medida em que sobre ela não houve indagação por autoridade. A iniciativa de comentar a conversa, admitindo seu conteúdo, mas contestando sua interpretação, foi da própria autoridade impetrada. Ela não estava sob interrogatório. Tomou a iniciativa de se pronunciar".

Portanto, aqui, utilizo como fundamento para valorar os elementos probatórios em favor do paciente, Luiz Inácio Lula da Silva, os mesmos argumentos com que justifiquei a possibilidade de valoração das interceptações ilícitas lá divulgadas pelo ex-Juiz Sergio Moro, naquele momento, desfavoráveis ao paciente.

Por fim, o debate aqui abordado toca diretamente na temática das **provas ilícitas no processo penal**. Trata-se de avanço primordial em um

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Estado Democrático de Direito, consolidado no art. 5º, LVI, da CF ("*são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos*") e no CPP, nos termos da reforma de 2008, consoante o art. 157, *caput*, "*são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais*".

Cuida-se de medida fundamental para a proteção do réu contra abusos no exercício do poder punitivo estatal. Assim, é intrigante perceber que tal garantia tem sofrido críticas, sendo objeto de propostas de relativizações, como aquelas apresentadas pelo próprio MPF (10 Medidas Contra a Corrupção).

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu pode justificar relativização à ilicitude da prova. Cite-se, por exemplo, a assentada possibilidade de que a gravação feita por um dos interlocutores seja utilizada:

> "O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência da Corte acerca da admissibilidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública, para anular o processo desde o indeferimento da prova admissível e ora admitida, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau e, neste julgamento, o Senhor Ministro Carlos Britto. Plenário, 19.11.2009". (RG na QO no RE 583.937/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 19.11.2009, DJe 17.12.2009).

Sobre a questão, no caso *Scheichelbauer vs. Áustria*, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos consignou que a gravação ilícita de um coacusado poderia ser incorporada ao processo penal, tendo em vista o direito de defesa do réu, para sustentar seu álibi.

A doutrina brasileira aceita a possibilidade de utilização de prova ilícita pró-réu, a partir do princípio da proporcionalidade, considerando o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

direito de defesa (GRINOVER, SCARANCE e FERNANDES, *Nulidades no processo penal. 7ª* ed. RT, 2001. p. 137). Isso porque:

> "É natural que no confronto entre uma proibição de prova, ainda que ditada pelo interesse de proteção a um direito fundamental, e o direito à prova da inocência este último deve prevalecer, não só porque a liberdade e a dignidade da pessoa humana constituem valores insuperáveis, na ótica da sociedade democrática, mas também porque ao próprio Estado não pode interessar a punição do inocente, o que poderia significar a impunidade do verdadeiro culpado; (...)". (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal brasileiro. *Revista Brasileira de Ciências Criminais,* v. 85, 2010, p. 409)

Afirma-se que "*desde o ponto de vista de a quem beneficia a ilicitude probatória, a questão central é determinar se a proibição de admissão ou valoração da prova ilícita deveria ter, como única exceção, aqueles casos em que os resultados beneficiem o imputado ou acusado, ou, inclusive, àquele que não tenha tido nenhuma relação com a ilicitude*" (ARMENTA DEU, Teresa. *A prova ilícita.* Marcial Pons, 2014. p. 82).

Isso se justifica também a partir das excludentes de ilicitude, pois "*quando o agente, atuando movido por algumas das motivações anteriormente mencionadas (causas de justificação), atinge determinada inviolabilidade alheia para o fim de obter prova da inocência, sua ou de terceiros, estará afastada a ilicitude da ação*" (PACELLI, Eugênio. *Curso de processo penal.* 22ª ed. Atlas, 2018. p. 379).

De modo semelhante, deve-se citar a doutrina do Min. Alexandre de Moraes, que também afirma a legitimidade da prova produzida em "*legítima defesa de seus direitos humanos fundamentais, que estavam sendo ameaçados ou lesionados em face de condutas anteriormente ilícitas*" (MORAES, Alexandre de. *Direito constitucional.* 32ª ed. Atlas, 2016. p. 123).

Portanto, os elementos de informação aqui analisados poderiam até mesmo ser plenamente admissíveis em sentido favorável ao réu no

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

processo penal.

De qualquer modo, reitero que a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível a partir dos fatos narrados na impetração original, de modo a se afastar qualquer eventual discussão sobre o tema da possibilidade de utilização da prova potencialmente ilícita pela defesa.

6. Dos fatos expostos neste caso concreto: indícios de uma parcialidade anunciada

A despeito da riqueza da experiência histórica recente, as alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e anteriores à sua impetração.

A fim de demonstrar a perda da parcialidade do magistrado, a defesa expõe 7 (sete) fatos que denotam o que alegado, quais sejam:

> "(a) o deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4.3.2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial;
>
> (b) a autorização para a interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas;
>
> (c) a divulgação, no dia 16.3.2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas;
>
> (d) o momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que "[A]s principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-Presidente Dilma e o Paciente";
>
> (e) a condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica, em sentença proferida no dia 12.7.2017;
>
> (f) na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, no dia 8.7.2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC 5025614-40.2018.4.04.0000; e
>
> (g) a aceitação do convite feito pelo Presidente da

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato".

Ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritas neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados. Daí porque, com as devidas vênias, tenho por improcedente a tese lançada no voto-relator no sentido de que parte dos fatos alegados na impetração já teria sido objeto de deliberação pelas instâncias do Poder Judiciário.

É que, para fins de se aferir a manutenção da **imparcialidade objetiva** do magistrado, o que se faz relevante não é apenas examinar se os atos por ele praticados isoladamente encontrariam agasalho na legislação aplicável. O que se deve investigar aqui é o significado contextualizado do encadeamento das decisões judiciais do ex-juiz; os motivos explícitos ou implícitos de prolação; as repercussões intencionais sobre a condução do processo; e, principalmente, as repercussões para a percepção **objetiva** sobre se o magistrado cumpre, ou não, o seu dever de independência.

Partindo-se da Teoria da Aparência Geral de Imparcialidade, a avaliação aqui desenvolvida, portanto, deve ter como parâmetro o prisma da imparcialidade objetiva.

Assim, não se cuida de discutir aqui se o juiz, na sua dimensão subjetiva, nutria afeição ou desapreço pelo acusado. O que se deve perguntar de forma simples e direta é: diante de todo o conjunto de atos jurisdicionais praticados por Sergio Moro, ainda é possível manter a percepção de que o julgamento do paciente deste HC foi realizado por um juiz despido de todo e qualquer preconceito acerca da culpabilidade do acusado? É ainda possível afirmar que a decisão condenatória assinada pelo magistrado serviria unicamente à realização do interesse da Justiça independente dos desígnios pessoais do magistrado? As respostas a essas duas questões, infelizmente, parecem ser negativas.

Examino a seguir cada um dos fatos denotativos da perda de parcialidade do magistrado.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

a) "ilegal condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva" (eDOC 4)

O **primeiro fato** indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão, datada de 4.3.2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente a sua intimação pessoal para comparecimento em Juízo, como exige o art. 260 do Código de Processo Penal:

> "Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença".

Cumpre observar que, antes da realização desse ato, o paciente já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 (quatro) vezes. Ou seja, sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado.

O que justificaria então a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condução *sob vara*? A leitura da decisão assinada pelo ex-juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era *sui generis* e que a sua escolha se dava pela exposição pública do ex-Presidente Lula. Nesse sentido, o magistrado tenta justificar que, *in verbis:*

> "Nesse caso, apontado motivo circunstancial relevante para justificar a diligência, qual seja evitar possíveis tumultos como o havido recentemente perante o Fórum Criminal da Barra Funda em São Paulo, quando houve confronto entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao ex-Presidente e que reclamou a intervenção da Polícia Militar.
>
> Colhendo o depoimento mediante condução coercitiva, são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra, já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas (...)"

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0